法学研究 Chinese Journal of Law
Vol.46，No.1（2024）

迈向自主法学知识体系的比较法研究范式

——以2003-2022年的比较法论文为样本

宋亚辉 *

内容提要：比较法在当代中国的兴起源于服务立法之使命，随着中国特色社会主义法律体系的逐步形成，比较法也在转型发展。以介绍和比较域外法为论题的“显性比较法”逐渐式微，借助比较法上的论据探讨本国问题的“隐性比较法”渐成主流；比较对象的选取日益受本国法体系约束，具有家族相似性的域外法愈发受青睐。这两个发展趋势寓意深远。由于法律问题往往深嵌于本土社会，问题的社会语境因此成为隐性比较法研究的制约因素；如果说社会语境只是一种软约束的话，本国法体系则是一种更为直接的硬约束。这两个约束条件不仅塑造了比较法的研究目标，而且限定了比较对象的选择，同时也影响了比较分析的方法和域外法素材的应用方式。这整体上构成了隐性比较法颇具中国特质的研究范式，其中蕴含着比较法学主体意识回归的积极信号。主体意识的回归是构建自主法学知识体系的关键所在，总体上契合了中国法治的发展进程。

关键词：比较法　法律移植　法系　范式转型　自主法学知识体系

在追求“中国自主的法学知识体系”的背景下，〔1〕以域外法和中外法律比较为研究对象的比较法学科将向何处去，是一个不容忽视的理论与现实问题。这一问题的回答取决于比较法研究对于中国法治国家建设和法学学科发展的意义。本文将从实证研究和规范分析两个视角尝试回答该问题。其中，实证研究部分将从最近二十年（2003-2022）的学术论文大数据中总结提炼比较法在中国的转型发展趋势；在此基础上，根据实证研究发现的两条规律，进一步对中国比较法的研究目标、比较方法和域外法素材的应用方式进行规范分析，进而展望中国比较法的未来。

---

* 南京大学法学院教授。
本文是国家社科基金重点项目“适应商业创新的市场规制体制研究”（21AFX020）的前期成果，并受中央高校基本科研业务费项目资助（010514370123）。感谢周麒、张耀鹤、金苗、哈嘉祁等同学协助识别和整理数据。

〔1〕 参见《中办国办印发〈关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见〉》，《人民日报》2023年2月27日第1版。

一、比较法在中国向何处去

（一）国家法治发展脉络中的比较法发展方向

比较法具有多重功能，包括但不限于服务国家立法和外交政策、作为法解释的工具、提炼一般法理论、提升法学教育水平、推动超国家的法律统一、增进人们对不同法律体系的了解等。从效用角度看，比较法向何处去，显然会受到国家法治发展需求的影响，不同阶段的需求会对比较法有不同的期待。

20 世纪中国比较法的诞生源于服务立法之使命，比较法的发展也与国家法治建设进程一脉相承。回顾 20 世纪三次大规模的外源型法制转型过程，比较法在其中均发挥了重要作用，〔2〕总体上是以服务立法为使命，以译介和比较域外法制为内容，致力于为中国法制转型提供域外参考资料，法律移植和借鉴是初创期比较法的主要任务。例如，在 20 世纪上半叶的两次大规模法制转型中，比较法的主旋律是借鉴大陆法系的法制；新中国成立初期，比较法全面转向苏联和东欧的法律；至改革开放后，比较法博采两大法系之长，试图通过借鉴域外先进立法和学说补足中国缺失的法律拼图。中国比较法正是在此背景下，以服务立法为己任、以译介和比较域外法制为内容而创生与发展。〔3〕1990 年代，各项立法如雨后春笋般颁布，法律起草过程中调研域外法已成常规性的准备工作，立法机关配套出版的释义性著作不乏对这一过程的介绍。其中，民商经济立法尤其仰赖学者对域外法制的引介，甚至 1982 年宪法的制定也比较了大量外国宪法。〔4〕在立法中参考域外法几乎是大陆法系的通例，〔5〕服务立法也成为中国比较法诞生时的首要使命，这种意义上的比较法被称为“供立法者作为资料的比较法”。〔6〕

当基础性的立法工作趋于完成后，法治建设的工作重心自然要向实践转移。此时，比较法的核心使命似乎也要从服务立法转向服务法律适用，后者又称“作为解释工具的比较法”。〔7〕这是否意味着中国比较法将进入第二个发展阶段？类似的推理和预测不绝于耳，尤其是 2011 年我国正式宣布“中国特色社会主义法律体系”基本形成之后。〔8〕在承前启后的历史时刻，学者曾预测我国的法学研究将从“体系前”大规模引进域外立法材料引致的外源型和立法论研究范式，转向“体系后”以中国问题为中心的解释论研究范式。〔9〕如今，学者期待的转型似乎正在发生，至少国内的学术导向更加强调立足中国问题和现行法的解释论研究。在这种研

〔2〕 以 20 世纪三次大规模的外源型法制转型为线索，学者将中国比较法的发展划分为三个阶段：一是 1911 年之前的清末修律阶段；二是 1912-1949 年的民国法制建设阶段；三是 1949 年之后新中国的法律改革阶段。参见潘汉典：《比较法在中国：回顾与展望》，《比较法研究》1990 年第 2 期，第 4 页以下。

〔3〕 有学者将我国改革开放初期（1978-1992）比较法研究的主要学术成就总结为三份期刊、三位代表人物和四部学术著作。参见高鸿钧：《改革开放与中国比较法学的成长》，《法学》2018 年第 8 期，第 3 页以下。

〔4〕 例如，“中国在 1982 年修订宪法时，系统地研究了 35 个国家的宪法”。王晨光：《不同国家法律间的相互借鉴与吸收——比较法研究中的一项重要课题》，《中国法学》1992 年第 4 期，第 42 页。作为参与者，潘汉典教授“为此重新译注当代东西方主要国家（西德、意大利、日本、法国、加拿大、罗马尼亚等国）最新的宪法文本和文献（包括法国的人权宣言在内）”。前引〔2〕，潘汉典文，第 9 页。

〔5〕 诚如学者所言，“今天，在许多国家里，对许多方面的问题，每一位追求高质量的立法者都认为，从比较法学方面拟就一般报告或者特别地以专家鉴定的方式提供资料，乃是不可缺少的工作手段”。［德］K. 茨威格特、H. 克茨：《比较法总论》，潘汉典等译，法律出版社 2003 年版，第 23 页。

〔6〕 同上引茨威格特等书，第 23 页。

〔7〕 同上。

〔8〕 参见吴邦国：《全国人民代表大会常务委员会工作报告》，《人民日报》2011 年 3 月 19 日第 1 版。

〔9〕 参见陈甦：《体系前研究到体系后研究的范式转型》，《法学研究》2011 年第 5 期，第 3 页。

究范式下，作为法解释工具的比较法是否会迎来春天，尚待检验。此外，比较法还有其他诸项理论和实践功能，这是否意味着比较法将在“体系后”时代走向繁荣发展，殊值期待。

无论是服务立法还是作为法解释的工具，抑或服务法学教育和理论研究，国家法治发展脉络下的比较法研究毕竟是借助域外素材服务本国法治建设。而在 2023 年《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》提倡“构建中国自主的法学知识体系”的背景下，“中国特色的法学学科体系、学术体系、话语体系”被提升到前所未有的高度。强调自主性是否意味着比较法不再重要？抑或需要新的比较法？这凸显了比较法发展方向的重要性。不只是政策导向，十多年前学界关于“中国法学向何处去”的大讨论也是以反思“中国为什么会缺失中国自己的法律理想图景”而展开的，学界虽有争议，但至少这场大讨论的开启者所描绘的理想图景“乃是一种依凭对中国现实的‘问题化’理论处理而阐明的中国本土的理想图景”。〔10〕这种反思西方中心主义、提倡法治本土化构建的主张在当下的比较法研究中是否正在发生，亦有待进一步验证。

（二）学说论辩脉络中比较法的多元发展方向

学术发展除受外部需求引导外，往往还有内在发展规律。比较法在中国的成长是从引进域外学说开始的。诚如学者所言，“中国比较法研究虽然得到了迅速发展，但是还没有形成系统的理论、方法和目标。如果说 20 世纪后期西方比较法研究的主要问题是传统范式面临挑战，那么，中国比较法研究的主要问题则是还没有形成自己的独特范式”。〔11〕因而，比较法学说脉络的梳理需要拓展至全球视角。1900 年在巴黎召开的比较法国际大会使比较法正式成为一项全球性的学术议题，这次大会的学术精神是探寻超国界的人类共同法，〔12〕这种精神引领了 20 世纪比较法的学术潮流，学界主要围绕不同法秩序的比较、借鉴与移植开展比较法研究。“二战”后，法律移植开始在众多第三世界国家付诸实践，但移植效果却参差不齐，这加剧了比较法的学说论辩，各种学说将比较法指向不同的发展方向。学说论辩的主线如下：

第一，“法律移植论”与比较法的发展方向。艾伦·沃森系统论证了法律移植的命题和比较法的学术使命。他认为，法律是可移植的，这是法律发展的主要途径，移植过程主要受到法律精英的影响，因而比较法研究和法学教育对于一国的法治转型意义重大。〔13〕他还认为，“法律在很大程度上是自治的，不受社会需求的影响”。〔14〕恰似语言在不同民族的推广一样，同一套法律转用于不同国家的情况比比皆是，法律可以脱离社会需求而独立存在（无机论）。如果说法律有塑造力量的话，这种力量并非一个民族的社会、政治、文化基础，而是法律传统本身，“民法法系和普通法系的基本区别是从法律传统方面来解释的；那就是，差异是法律史的结果，而非由社会的、经济的或政治的历史造成的”。〔15〕根据这种学说，比较法的学术使命是追溯法律传统、探寻法律家族意义上的渊源关系、解析法系之间的差异，以便为法律移植和法律发展探寻道路，这为比较法指明了发展方向。

〔10〕 邓正来：《中国法学向何处去（上）——建构“中国法律理想图景”时代的论纲》，《政法论坛》2005 年第 1 期，第 7 页。

〔11〕 高鸿钧：《比较法研究的反思：当代挑战与范式转换》，《中国社会科学》2009 年第 6 期，第 165 页。

〔12〕 参见前引〔5〕，茨威格特等书，第 3 页以下。

〔13〕 See Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, 2d ed., Athens and London: The University of Georgia Press, 1993, pp. 108-118.

〔14〕［英］艾伦·沃森：《法律演化》，余成峰译，商务印书馆 2022 年版，第 159 页。

〔15〕［美］艾伦·沃森：《民法法系的演变及形成》，李静冰、姚新华译，中国法制出版社 2005 年版，第 2 页。

第二，“文化依赖论”与比较法的发展方向。以劳伦斯·弗里德曼为代表的法社会学者强调“法律文化”的决定性意义，认为地域文化决定着法律移植的成败，因为“活法的某些部分深嵌于民族文化之中，……研究法律文化会发现自发型或强加型法律变革的发生条件。对于强加型法律变革，法律文化的约束条件决定了变革的成功或失败”。〔16〕这是“文化依赖论”之要义。弗里德曼并未否定法律移植的可能性，但罗格朗则认为，法律规则是由“词语形式（纯粹的命题性陈述）”和“规则的意义”两个要素构成，前者虽可移植，但后者属于文化范畴，不可移植，由于规则离开了意义之维就不再是原来的规则，因而“纯粹的命题性陈述与其意义之间的分离阻止了规则本身的迁移”。〔17〕例如，“二战”后兴起的以法律移植为内容的“法律与发展运动”的衰落，正是归因于地域文化的约束。〔18〕根据这种学说，比较法应聚焦于研究法律生长的社会土壤，揭示法律类型与社会样态的适配性。若认为法律根本不可移植，则比较法的意义主要在于以文化视角来理解他者。

第三，“法律移植多元论”与比较法的发展方向。上述两种理论并未覆盖比较法的所有学说，但却构成了学说论辩的主线，也是观点交锋的主战场。此外，还有不少介于中间状态的学说。例如，国内学者在评述既有理论时，发现各种学说都存在一些反例，并认为不同性质的法律规则也存在可移植性上的差异，进而区分了人类社会的不同历史阶段和不同规则类型，对法律移植命题作出了多维度的解读，〔19〕本文称之为“法律移植多元论”。从学术脉络来看，该理论是对“文化依赖论”的扬弃和发展，进而也将比较法引向了法与社会互动的多维视角。

上述学说将比较法指向了不同的发展方向，孰是孰非，尚无定论。各种学说似乎也都有例证支撑。例如，罗马法的全球传播和欧盟的法律一体化似乎为“法律移植论”提供了最佳论据，该理论盛极一时；〔20〕而“法律与发展运动”的四十年兴衰史似乎又为“文化依赖论”提供了强力背书。〔21〕学界因此陷入持久的争论中。对中国而言，在构建自主法学知识体系的背景下，比较法又该向何处去？“法律移植论”和“文化依赖论”各自描绘的比较法前景，能否服务于自主法学知识体系的构建？本文将立足中国来探讨这些问题。

二、中国比较法从显性向隐性的转型趋势

学术发展趋势往往蕴含在学术作品中。本文以第一版 CLSCI 收录的 15 本刊物〔22〕（以下

〔16〕 See Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, 4 Law & Soc. Rev. 29, 38 (1969).

〔17〕 ［法］P. 罗格朗：《何谓“法律移植”》，马剑银译，载［意］D. 奈尔肯、［英］J. 菲斯特主编：《法律移植与法律文化》，高鸿钧等译，清华大学出版社 2006 年版，第 88 页。

〔18〕 See David M. Trubek & Marc Galanter, *Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States*, 4 Wis. L. Rev. 1062, 1090 (1974).

〔19〕 根据人类社会的三个不同发展阶段（初民社会、民族国家时代、全球化时代），学者提出了三种穿越不同文化的法律移植模式；根据哈贝马斯区分的三种规则类型（实用性规则、伦理性规则、道德性规则），学者还从不同规则维度讨论了法律移植的多元论，认为除伦理性规则外，其他规则都可移植。参见高鸿钧：《文化与法律移植：理论之争与范式重构》，《环球法律评论》2008 年第 5 期，第 5 页以下。

〔20〕 See John W. Cairns, *Watson, Walton, and the History of Legal Transplants*, 41 Ga. J. Int'l & Comp. L. 637, 672-686 (2013)；余成峰：《超越历史社会的“法律移植”——纪念艾伦·沃森》，《读书》2019 年第 11 期，第 174 页。

〔21〕 See David M. Trubek, *Law and Development: Forty Years after Scholars in Self-Estrangement*, 66 U. Toronto L. J. 301, 303-326 (2016).

〔22〕 第一版 CLSCI-15 的刊物清单如下：《中国社会科学》《法学研究》《中国法学》《中外法学》《法学家》《法商研究》《法学》《法律科学》《现代法学》《比较法研究》《环球法律评论》《清华法学》《政法论坛》《法制与社会发展》《法学评论》。2003-2022 年，这 15 本刊物均正常出版发行。

简称“CLSCI-15”）在2003-2022年发表的域外法和比较法（本文统称“比较法”）方向的学术论文为样本，观察比较法的发展趋势。之所以选择CLSCI-15作为样本来源，主要考虑到其是最近二十年法学领域最具影响力的刊物群，学术认可度较高、年度发文量相对稳定，便于观察比较法论文的年度变化与发展趋势。学术性不强的刊物可能存在较多因猎奇心理和趣味性考虑而刊发的域外法文章，对于观察学术范式的转型意义有限。

（一）2003-2022年比较法研究的整体走势

2003-2022年，CLSCI-15共刊载了28897篇文章，〔23〕通过阅读这些文章的篇名、关键词、摘要（以下简称“篇关摘”），本文共筛选出4884篇比较法论文，占总样本数的16.9%。在筛选标准上，本文对“比较法论文”采广义理解，将真正做比较研究的论文和介绍域外法或域外理论的论文都统计在内。严格来讲，后者只能算是“叙述的比较法”，〔24〕但考虑到真正的比较法要以叙述域外法为前提和素材，且改革开放初期的比较法论文也多以叙述域外法为内容和样式，因而也将其纳入统计范围。在信息来源上，本文仅依据“篇关摘”筛选比较法论文，未扩展至正文。因为“篇关摘”反映的是一篇论文的核心命题与观点，据此识别出的比较法论文更具典型性，可反映出主流的比较法研究样式。若将识别依据拓展至全文，不仅不确定性陡增，而且会影响本文对主流比较法研究范式的提炼。因为法学论文附带提及域外法或引用域外文献的情况俯拾皆是，〔25〕这种情况能否视为比较法论文、多大篇幅的域外元素才算比较法论文，皆不确定，这会严重影响样本识别的精确性。本文认为，一笔带过的域外法介绍难谓比较法研究，只有作者足够自信地在论文“篇关摘”中提及域外法或比较法元素，才会纳入本文的观察视野。

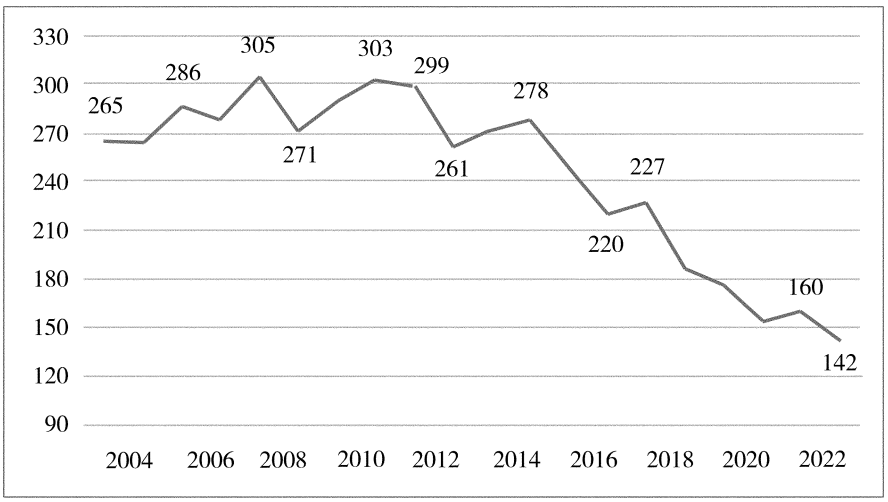

图1　2003-2022年比较法论文数量的年度变化趋势

〔23〕该数据通过中国知网（CNKI）数据库自动检索获得，未作任何筛选。检索方法为：选取“学术期刊”子库，在“高级检索”中将“来源期刊”选定为前述15本刊物，时间限定为2003-2022年，据此检索出28897个文章条目。随后将“篇名、关键词、摘要”批量导入excel表格，以备后期筛选。检索日期截至2023年1月11日。

〔24〕前引〔5〕，茨威格特等书，第9页。

〔25〕学界对法学论文引注的抽样调查发现，“翻译文献和直接外文文献共占41.4%”。熊谋林：《三十年中国法学研究方法回顾——基于中外顶级法学期刊引证文献的统计比较（2001-2011）》，《政法论坛》2014年第3期，第18页。

本文将这 4884 篇比较法论文按发表年度连线生成图 1。该图显示，比较法论文发表量在这二十年间先升后降，拐点出现在 2010-2011 年间，此前的年度发文量稳中有升，此后急速下跌，至 2022 年已跌至不足 2011 年的一半。2011 年成为拐点并不意外，这一年是中国法治发展进程的重要节点，我国正式宣布“中国特色社会主义法律体系”基本形成。我国作为法治后发国家，立法工作离不开对域外法的参考，这是比较法在中国兴起的主要原因，也是国际公认的比较法的重要功能之一。随着本国法律体系的逐步形成，服务立法的需求逐步减弱，比较法论文发表量随之锐减，似乎也在情理之中。

（二）显性比较法与隐性比较法的分化趋势

比较法论文发表量的锐减固然有需求端的原因，但如此明显的跌幅还是令人忧虑。毕竟立法工作在 2011 年之后并未停止，如互联网立法方兴未艾；更何况，服务立法并非比较法的唯一功能，比较法在服务法解释、提炼法理论、优化法学教育等方面的功能在任何时候都有一定的市场；而且比较法的基础性功能是增进人们对法律的了解，〔26〕凡有认知需求之处就有比较法的市场。由此引发的问题是，2011 年之后比较法论文的锐减，究竟意味着比较法的整体衰落，还是预示着比较法的转型发展？这需要对样本进行分类观察。学界曾以不同的标准对比较法作过不同的分类，如外国法与真正的比较法、立法比较法与学术理论的比较法、〔27〕规范比较法与功能比较法、〔28〕法解释的比较法与法政策的比较法等。由于一篇比较法论文往往会运用多种比较方法，上述精细化的分类标准并不适合以整篇论文为单位的样本区分。

为此，本文采用一个更简洁的分类，即根据域外法和比较法元素在论文中的角色属于“论题”还是“论据”，将样本区分为“显性比较法论文”和“隐性比较法论文”。前者是指以域外法或比较法为“论题”的论文，这类比较法论文可从标题直接被识别，因而谓之“显性”；后者是指将域外法或比较法元素依附于具体问题之下，以解决问题之“论据”形式呈现的论文，因而谓之“隐性”。精确辨别“论题”和“论据”，本应通读全文来判断，但这会引入大量主观因素，影响分类数据的可验证性。为确保后续生成的数据可检验，本文对分类标准作客观化处理，即根据域外法和比较法元素在论文中出现的位置进行分类。

第一，若论文标题（含副标题）中涉及域外法或比较法元素，本文将其归入显性比较法论文。由于论文标题通常表达的是研究对象、问题、论点、视角或方法，若此处涉及域外法或比较法元素，多数属于以此为“论题”的论文。举例来看，《中国社会科学》在这二十年间发表了 41 篇比较法论文，其中 21 篇为显性比较法论文，如《中国民法继受潘德克顿法学：引进、衰落和复兴》表达了法律继受的“论点”；〔29〕《两大法系法律实施系统比较——财产法律的视角》和《论〈法国民法典〉对罗马法信托概念的引入》分别以比较法和外国法为研究“对象”；〔30〕《法定物权的社会成本——两岸立法政策的比较与建议》表达了比较之“视角”和两岸立法的成本“问题”。〔31〕

〔26〕 参见［意］罗道尔夫·萨科：《比较法导论》，费安玲等译，商务印书馆 2014 年版，第 16 页以下。

〔27〕 “立法比较法”是“在创造新的本国法律之际参考外国法”，“学术理论的比较法”是“为了更好地认识法律起见，对不同的法律制度进行的比较的考察”。前引〔5〕，茨威格特等书，第 76 页。

〔28〕 参见朱淑丽：《挣扎在理想与现实之间：功能主义比较法 90 年回顾》，《中外法学》2011 年第 6 期，第 1280 页。

〔29〕 参见孙宪忠：《中国民法继受潘德克顿法学：引进、衰落和复兴》，《中国社会科学》2008 年第 2 期，第 88 页。

〔30〕 参见冉昊：《两大法系法律实施系统比较——财产法律的视角》，《中国社会科学》2006 年第 1 期，第 59 页；李世刚：《论〈法国民法典〉对罗马法信托概念的引入》，《中国社会科学》2009 年第 4 期，第 106 页。

〔31〕 参见苏永钦：《法定物权的社会成本——两岸立法政策的比较与建议》，《中国社会科学》2005 年第 6 期，第 79 页。

第二，若论文标题中并无域外法或比较法元素，但摘要或关键词提及了域外法或比较法元素，这类论文大多是在研究本国问题或超国界的一般问题时将比较法元素作为“论据”使用，本文将其归入隐性比较法论文。以《中国社会科学》刊载的隐性比较法论文为例，《价值判断与中国刑法学知识转型》一文聚焦中国问题，但其摘要提及“欧陆刑法发展史表明了刑法价值判断的极端重要性”，〔32〕该文借助域外刑法学的价值判断理论分析中国刑法学的转型。又如，《生命价值的法律与经济分析——中国生命赔偿法律的改革路径》也聚焦中国问题，但其摘要写道，“西方学界形成了人力资本法和意愿支付法两种计算生命价值的方法”，〔33〕该文借鉴域外方法解决中国面临的生命赔偿计算难题。

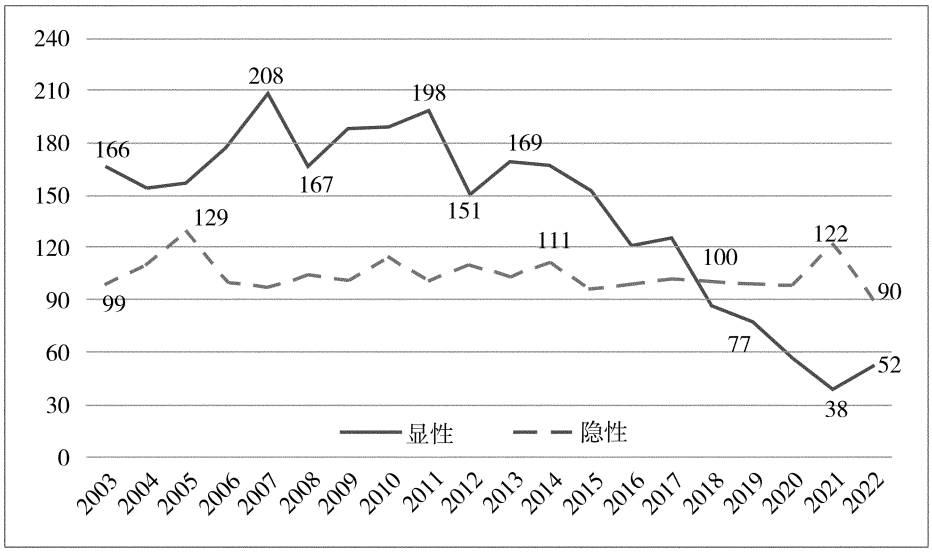

图 2　2003-2022 年比较法论文的显性与隐性分化趋势

依上述标准分类统计后发现，4884 篇比较法论文中，有 2801 篇属于显性比较法论文（占比 57.35%），2083 篇属于隐性比较法论文（占比 42.65%）。二者的发展走势截然不同。图 2 显示，隐性比较法论文在 2003-2022 年保持相对稳定，年度发文量维持在 100 篇左右；而显性比较法论文自 2011 年之后一路下跌，跌幅与比较法论文的整体跌幅（图 1）大致相当。这表明，比较法论文的锐减主要发生在显性比较法领域，而隐性比较法论文则在稳步发展。此外，考虑到本文仅依据“篇关摘”识别比较法论文，若阅读正文，则隐性比较法论文数量会更多，因为并非所有隐性比较法论文都会在“篇关摘”中提及比较法元素。〔34〕若引入这一变量，则图 2 传递的信号将更为积极，反映出隐性比较法在我国的稳健发展。

（三）比较法从显性向隐性转型发展之意蕴

显性比较法的式微与隐性比较法的稳健发展，表明中国比较法整体上朝着隐性比较法的方向演进，这在一定意义上也是一种转型。该趋势值得关注，有望逐步改变学者在十多年前对中

〔32〕 周光权：《价值判断与中国刑法学知识转型》，《中国社会科学》2013 年第 4 期，第 120 页。

〔33〕 李本森：《生命价值的法律与经济分析——中国生命赔偿法律的改革路径》，《中国社会科学》2011 年第 6 期，第 79 页。

〔34〕 例如，一篇关于赌博借贷的文章，其正文详述了德国法上的赌债教义学及其对中国的借鉴意义，是典型的隐性比较法论文，但“篇关摘”中却无任何比较法元素，因而未纳入本文的统计范围。参见冯洁语：《论赌博借贷的民法教义学构造——以从赌博到赌博借贷的公私法体系透视为线索》，《法律科学》2020 年第 4 期，第 139 页以下。

国比较法“还没有形成系统的理论、方法和目标”的评价。[35] 本文的这一判断主要源于隐性比较法蕴含的以下三个潜在趋势：

第一，逐步回归本国问题。隐性比较法的首要特点是将域外法或比较法元素依附于具体问题之下，以解决问题之“论据”的方式引入域外法。从本文收集的隐性比较法论文样本来看，这些论文关注的问题复杂多样，既有立法方面的问题，也有法解释问题，还有一般法理论问题。总体来看，这些论文的问题意识多来自中国，回归本国问题正成为隐性比较法的发展趋势之一。

第二，问题的社会语境成为制约因素。一旦将解决实际问题作为比较法的立论目标，则对于高质量的研究而言，发现问题、分析问题、解决问题的过程自然会触及问题所嵌入的社会语境，因为问题往往只是冰山一角，还原整体环境才能准确分析问题。因此，社会语境成为隐性比较法研究的制约因素。

第三，域外法多为解决本国问题之论据。相较于译介域外法或直接以域外法律问题为“论题”的显性比较法而言，隐性比较法的另一发展趋势是将域外法元素作为解决本国问题之“论据”。常见的情况是追溯域外法的由来和发展演变，借助域外经验分析并解决本国问题，或吸取域外教训，避免本国重蹈覆辙。

上述趋势总体描绘了隐性比较法的发展方向，表明回归本国问题、正视社会语境、借域外论据为我所用正成为比较法研究的大势所趋。当然，这只是笔者的整体观察，若关注细节，隐性比较法论文忽视社会语境的情况也时有发生，论据选取上的“拿来主义”也屡见不鲜。[36] 但这并非隐性比较法自身的特质，而是研究者分析问题、引用论据的方式失之粗糙所致。不过，隐性比较法也有其结构性问题值得重视：（1）这种文体无法容纳对域外法体系脉络的整体介绍，浅尝辄止的问题不容忽视；（2）这类研究主要立足本国问题择取域外的比较对象，而鉴别过程又不易展示，这种内部视角和暗箱处理容易引发“留学国别主义现象”，[37] 影响比较对象的契合度；（3）这种趋势孕育的比较法学者多为研究具体部门法的“兼职者”，不易培养专职从事跨法系比较研究的学者。

但总体上，回归本土问题、正视社会语境的隐性比较法有望引领下一阶段比较法的发展方向。至于转型原因，主要有两个方面：（1）国家法治建设的重心逐渐向实践转移，导致“供立法者作为资料的比较法”的实践意义逐渐减弱，而隐性比较法重在解决实际问题，这契合了国家需求的变化。无论是法的修订还是解释适用，抑或一般法理论的提炼，都离不开隐性比较法的贡献，由此实现了需求与供给的匹配。（2）国内的学术政策和学术品位日益强调中国原创，刊物的偏好和评价标准也更重视中国问题和原创性学术贡献，主流学者不再满足于单纯的域外法介绍或规范比较，学术重心逐渐转向域外法对解决本国实际问题的意义。这些变化孕育了比较法从显性向隐性转型的趋势。

---

〔35〕 前引〔11〕，高鸿钧文，第 165 页。

〔36〕 诚如学者所言，“目前，国内主流的比较法研究成果多是直接从外国法的制度、学说中汲取营养，通过对外国法的介绍和简单的分析，就直接得出我国法也应采取相同或者类似理论、立场的结论”。解亘：《正当化视角下的民法比较法研究》，《法学研究》2013 年第 6 期，第 9 页。对国内比较宪法学领域类似现象的总结，参见刘晗：《中国比较宪法学的重新定位与方法论重构》，《中国法学》2022 年第 2 期，第 77 页。

〔37〕 参见卜元石：《中国法科学生留学德国四十年的回顾与展望——基于博士学位论文的考察》，《法学研究》2019 年第 2 期，第 21 页。

三、本国法体系约束下的比较法转型方向

（一）2003-2022 年比较对象的跨法系转移

根据比较对象的国别（含地区，下同），本文对 CLSCI-15 在 2003-2022 年发表的比较法论文进行分类统计。结果显示，大多数（97.44%）比较法论文都在两大法系之间选取比较对象。其中，以大陆法系为比较对象的论文占比较法论文总数的 43.33%，以英美法系为比较对象的相应比例为 34.07%，另有 20.05%的论文跨两大法系进行比较。从国别来看，大陆法系最受青睐的是德国法、日本法和欧盟法，英美法系最受青睐的是美国法和英国法。

表 1　2003-2022 年比较法论文中比较对象的国别分布

法系	占比	地域	论文量	占比	论文总量
大陆法系	43.33%	德国	530	10.85%	2116
		日本	256	5.24%	
		欧盟/欧洲	227	4.65%	
		法国	95	1.95%	
		俄罗斯	53	1.09%	
		中国台湾地区	50	1.02%	
		意大利	24	0.49%	
		中国澳门特别行政区	19	0.39%	
		韩国	18	0.37%	
		瑞士	11	0.23%	
		荷兰	8	0.16%	
		奥地利	5	0.10%	
		巴西	4	0.08%	
		加拿大（魁北克省）	3	0.06%	
		越南	2	0.04%	
		瑞典	2	0.04%	
		阿根廷	2	0.04%	
		其他国家〔38〕	13	0.27%	
		横跨多个国别	794	16.26%	
英美法系	34.07%	美国	1080	22.11%	1664
		英国	161	3.30%	
		中国香港特别行政区	81	1.66%	
		印度	27	0.55%	
		加拿大	14	0.29%	
		澳大利亚	12	0.25%	
		南非（公法）	5	0.10%	
		新加坡	1	0.02%	
		横跨多个国别	283	5.79%	

〔38〕 仅有 1 个样本的国家或地区较多，本文在列表中将其合称为“其他国家”，含波兰、芬兰、匈牙利、卢旺达、美国（路易斯安那州）、南非（私法）、挪威、葡萄牙、西班牙、丹麦、土耳其、蒙古、智利。

（续表 1）

法系	占比	地域	论文量	占比	论文总量
横跨两大法系〔39〕	20.05%	横跨属于两大法系的多个国别	979	20.05%	979
其他	2.56%	非洲	10	0.20%	125
		伊斯兰国家	2	0.04%	
		国别不明（比较法/西方）	113	2.31%	

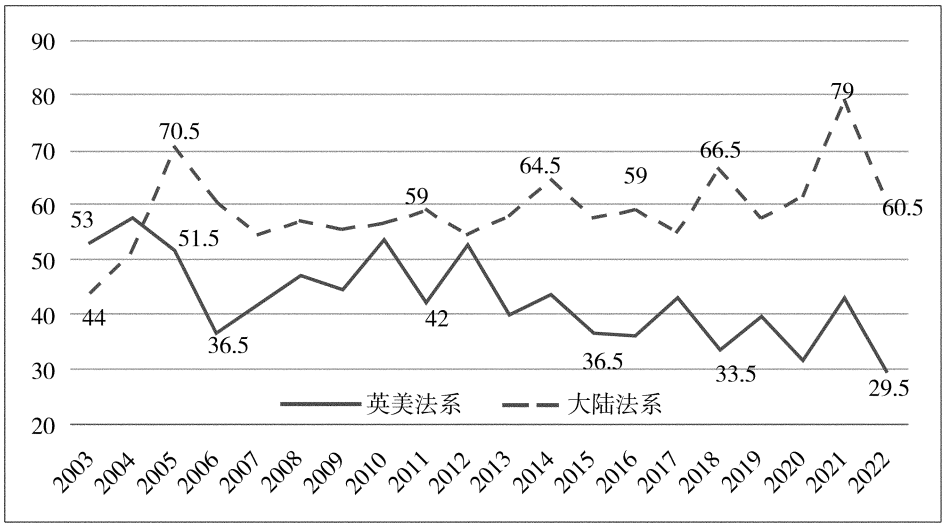

图 3　2003-2022 年隐性比较法论文中比较对象的法系差异〔40〕

值得关注的是，在比较对象的国别分布上，显性和隐性比较法论文也有显著差异。综合二十年的数据来看，显性比较法论文对两大法系给予了同等程度的关注（英美法系 1086 篇，大陆法系 1096 篇），但隐性比较法论文更青睐大陆法系。图 3 显示，隐性比较法论文对大陆法系的关注度明显高于英美法系，且差距还有不断扩大之势。仅在 2003-2004 年的短暂期间，关注英美法系的隐性比较法论文数量略胜一筹，但关注大陆法系的隐性比较法论文自 2005 年之后实现反超，并一路领先。图 3 中代表大陆法系的曲线呈波浪式上升趋势，代表英美法系的曲线整体呈下跌趋势。这种此消彼长的趋势表明，隐性比较法在比较对象方面的偏好正在发生转移，整体上越来越偏好大陆法系。由此引发的疑问是：

第一，中国法秉承了大陆法系的成文法传统，为何显性比较法论文对英美法系也高度关注？〔41〕这与“法律移植论”提倡的比较法研究应当追溯法律传统的发展方向似有不同。

第二，在比较法论文数量整体锐减的背景下，关注大陆法系的隐性比较法论文数量为何逆势增长？这尤其难能可贵。而且，大陆法系已整体超越英美法系成为国内学者更青睐的比较对

〔39〕“横跨两大法系”的样本包括三类：一是论文“篇关摘”提及了两大法系；二是提及了属于两大法系的两个以上的国家或地区；三是提及了属于混合法系的国家或地区，如英国（苏格兰）、菲律宾等。

〔40〕这里只计算“英美法系”“大陆法系”“横跨两大法系”的数据，不含表 1 中的“其他”类。“横跨两大法系”的论文数据被平分给“英美法系”和“大陆法系”，各赋值一半，图中数据因此出现了小数点。

〔41〕学界早期也有类似判断，认为 20 世纪 90 年代后国内尤其重视对英美国家公法的比较研究。参见前引〔11〕，高鸿钧文，第 163 页。

象。这种此消彼长的原因何在？

关于第一个问题，在改革开放早期，除个别法律分支外，比较法研究大多是在缺乏本国法体系约束的情况下，以开眼看世界的心态译介和比较域外法，形式上以显性比较法为主流，而显性比较法是一个自由竞争的学术市场，学者可自由选取域外法进行译介或比较分析。当时的立法精神和学术导向也鼓励博采众长地参考古今中外一切先进立法。〔42〕我国在立法形式上虽采用大陆法系的样式，但在内容上对两大法系并无固定偏好。〔43〕在此背景下，比较对象的选择主要取决于学者的知识背景和兴趣。其中，外语基础是关键。英语在改革开放初便在义务教育阶段推广，而德语、法语、日语等大陆法系国家的语言并未普及，语言障碍直接影响了比较对象的选择。于是便不难理解，国内早期的比较法为何也重视英美法系，宪法和行政法尤甚，毕业于美国的海归学者的学术影响力也更胜一筹。〔44〕总体上，在缺乏本国法体系约束的年代，比较法研究以译介域外法和规范比较为主流，比较对象的选择主要取决于语言工具和学术兴趣。受英美国家语言优势和国际地位的影响，英美法系在改革开放早期的比较法中也备受青睐。

关于第二个问题，从直观上看，近年来留学大陆法系国家的法学博士数量激增，〔45〕这无疑会带动大陆法系方向的比较研究，但这只是表面因素。关注大陆法系的隐性比较法论文的逆势增长，根本上源于隐性比较法自身的特质。隐性比较法是一种问题导向和目标导向的比较法，在解决本土问题的目标下，研究者不能忽视问题的社会语境，更不能忽视本国法体系的约束。后者不仅限定了比较对象的选择，而且塑造了中国比较法的发展方向。

在本国法律框架形成后，比较对象的选取也开始受限，学者只要在意比较法研究对于解决本国问题的意义，势必无法忽视本国法体系的约束。在环环相扣的成文法体系安排中，任何变化都可能牵一发而动全身。〔46〕比较法研究一旦正视并回归本国法体系的约束，具有可比性的域外法也就随之确定了。以反垄断法为例，美国和欧盟的反垄断法是学界关注的两个范本，在中国反垄断法颁布前，二者似无高下之分，美欧的差异源自双方不同的市场经济体制所蕴含

〔42〕 例如，时任中央政法委书记和全国人大常委会副委员长的彭真同志，1980 年 11 月 17 日在《对特别法庭旁听人员的讲话》中指出："我们在立法时，不论外国的法律、法理，还是中国历史上的法律、法理，都要研究，对我们有用的好东西要吸收，各种意见都可以百家争鸣。"1982 年 7 月 22 日彭真在中国法学会成立大会上所作的《发展社会主义民主，健全社会主义法制》的讲话中指出："法学会要研究古今中外的法律，不管进步的、中间的、反动的，不管是奴隶主的、封建的、还是资本主义的，都要研究，取其精华，去其糟粕和毒素。"彭真：《论新中国的政法工作》，中央文献出版社 1992 年版，第 236 页，第 295 页。

〔43〕 关于这一判断，参见 Jianfu Chen，*The Transformation of Chinese Law*：*from Formal to Substantial*，37 Hong Kong L. J. 689，708（2007）。

〔44〕 1998-2007 年的数据显示，国内一流法学院的海归学者与非海归学者的学术表现并无实质差异，唯一的例外是，"自美国获得学位者，其学术表现优于国内学位获得者"（也优于来自其他国家的海归学者）。张巍：《"海龟"比"土鳖"跑得更快吗？——针对中国一流法学院师资学术表现的一个计量研究》，载《光华法学》2009 年第 4 辑，法律出版社 2009 年版，第 25 页。

〔45〕 以德国为例，改革开放"初期留德人数很少，从 1989 年到 2000 年，一般每年一两个人、最多时有五个人毕业。……2001 年到 2009 年，在德国攻读法学博士学位的学生数量快速平稳增长，通常每年可以达到接近 10 名博士毕业的水平，在 2010 年之后跃升为年均 15-20 人左右，2015 年后提升到每年 20 人以上。……中国学生……目前已经构成外国留学生在德国攻读法学博士学位的重要群体"。前引〔37〕，卜元石文，第 5 页。

〔46〕 典型如我国公司法 2013 年的认缴制改革，这种政策驱动下的修法因未考虑体系安排，引发了大量法律适用难题。参见丁勇：《认缴制后公司法资本规则的革新》，《法学研究》2018 年第 2 期，第 155 页。经过十年的实施和检验，2023 年 12 月 29 日公布的公司法修订方案对此作了大量的体系修复工作。

的价值观分野（美国崇尚自由市场，欧盟强调引入社会价值）。然而，自中国颁布了以欧盟法为蓝本的反垄断法后，法的内在价值体系与外在制度体系的融贯性要求，决定了欧盟法的分析框架通常更具可比性和解释力。这蕴含的启示是："建立在一定先验基础上的法律体系在一般意义上并无绝对优劣之分，但在确定的前提假设下保持法律体系的逻辑一致性则具有内在的巨大价值。"〔47〕整体上，中国的法律体系与大陆法系一脉相承，都是在宪法统摄下，以公私法的二分、实体法与程序法的分化为框架，以部门法为基本单元构建的成文法体系。中国的法律规则纵然与欧陆国家多有不同，但在成文法的法源、体系性思维、实施机制和法解释方法等方面具有家族相似性，由此决定了比较对象的选择自然会偏向大陆法系，这正是体系约束之体现。

体系约束之所以根深蒂固，是因为大陆法系的法律体系根本上是由法学家逻辑构建的结果，其目标是"将众多的规范与事实问题安排进一个秩序里，由此创造出一个统一体"，〔48〕其精髓在于体系融贯性，因而被称为"法学教授之法"。〔49〕不仅规范与规范之间保持体系上的联动，而且法的内在价值体系与外在规范体系之间也保持着深度互动，由此塑造了大陆法系成文法的体系化品格。这也是理解成文法的一把钥匙。相较之下，"法官造法"的传统使得英美法的舞台中心在法院，象牙塔内学者的作用及面临的约束相对较弱，于是便不难理解英美的法学教授为何拥有更为洒脱的整体形象。〔50〕因体系约束之故，国内学者在两大法系之间选取比较对象时，取舍的准则和方向也基本清晰。在体系化程度越高、体系约束越强的领域，比较法研究越倾向于选择具有家族相似性的域外法作为比较对象。因此，只要承认中国法整体上是大陆法系的一员，隐性比较法倾向于选择大陆法系作为比较对象就顺理成章。这正是图 3 中代表两大法系的曲线此消彼长的根源。

（二）法学二级学科内部的微观差异

法体系的约束决定了国内的比较法研究整体上更关注大陆法系，但这只是整体情况。若区分不同法学二级学科来看，本文的数据显示，各法学二级学科虽然都重视比较法研究，〔51〕但因各部门法的体系化程度不同，比较法研究面临的体系约束也有差异；再加上各部门法在形式、内容等方面与两大法系的亲缘关系远近有别，如民法和刑法更接近大陆法系，商法在内容上似乎更偏向英美法系，由此决定了不同二级学科的比较法研究在选取比较对象时也各有侧重。图 4 例示了四个主要法学二级学科的比较法论文（含显性和隐性）在选取比较对象方面的整体差异。

---

〔47〕 李剑：《中国反垄断法实施中的体系冲突与化解》，《中国法学》2014 年第 6 期，第 138 页。

〔48〕 陈爱娥：《法体系的意义与功能——借镜德国法学理论而为说明》，《法治研究》2019 年第 5 期，第 55 页。

〔49〕 ［美］约翰·亨利·梅利曼、［委］罗格里奥·佩雷斯·佩尔多莫：《大陆法系》，顾培东、吴荻枫译，法律出版社 2021 年版，第 66 页以下。

〔50〕 尤其是美国的法学教授，他们更是自由驰骋于法学与其他学科的交叉地带，如社会学、人类学、经济学、文学和认知科学等。See Stephen M. Feldman, *The Transformation of an Academic Discipline: Law Professors in the Past and Future (or Toy Story Too)*, 54 J. Legal Educ. 471, 492 (2004).

〔51〕 法学二级学科的划分标准有一定弹性，本文尽量遵循学界惯例，根据论文讨论的主要议题，将 4884 篇比较法论文分别归入 11 个法学二级学科。经统计，各法学二级学科的比较法论文数量占比较法论文总量的比例依次为：民法 18.41%、诉讼法 15.15%、宪法与行政法（含行政诉讼法）14.91%、刑法 9.60%、法学理论 9.34%、商法 8.60%、经济法 7.96%、国际法 6.51%、法律史 3.95%、知识产权法 3.62%、环境资源法 1.95%。

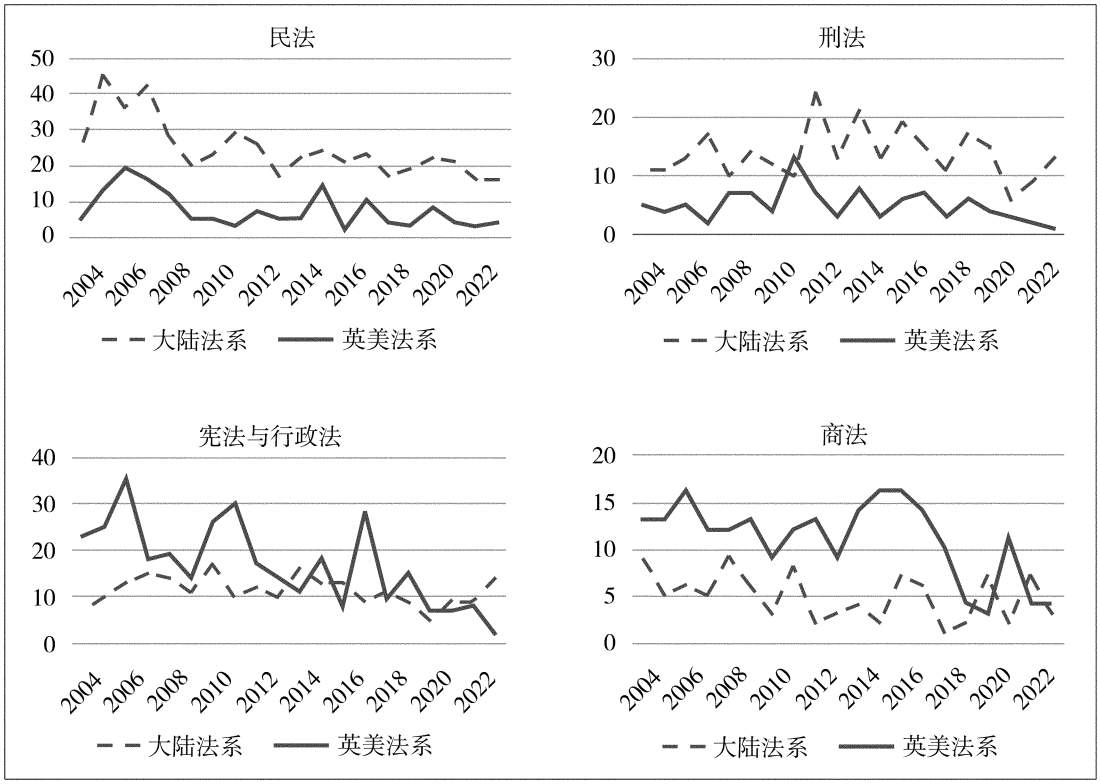

图 4　2003-2022 年不同法学二级学科中比较对象的法系差异

首先，以民法、刑法为代表的传统学科的体系化和法典化程度较高，对于比较法研究而言，这两个学科受本国法体系的约束也较强。图 4 显示，民法和刑法的比较法论文主要选择具有家族相似性的大陆法系作为比较对象。当然，这两个学科对英美法系也有关注，这常见于显性比较法论文以及法经济学、法社会学和网络空间的民法、刑法议题，且多采用功能主义的比较方法。功能比较不在意规范本身的近似性与体系相关性，只要功能近似，均具有比较意义。

其次，相较于民法和刑法，以宪法与行政法、商法为代表的相对晚近的学科的体系化和法典化程度不高，比较研究面临的体系约束也相对较弱，比较对象的选取更为自由开放。受语言优势影响，再加上英美公法自启蒙运动以来飞速发展，美国商法更是随经济全球化而辐射全球，〔52〕导致这两个学科的比较法研究更关注英美法系。新科技革命催生的法律分支也倾向于以英美法系作为比较对象，如知识产权法、网络法等，这与美国的科技竞争力不无关联。

最后，比较对象的二级学科数据再次印证了本文的如下判断：法体系的约束塑造了比较法的发展方向，体系化程度越高的二级学科在比较法研究中对大陆法系的依赖度越强；反之，体系化程度越低的二级学科对大陆法系的依赖度越弱。此外，从比较法的显性与隐性分化来看，体系化程度越高的二级学科从事隐性比较法研究的比例也越高，如民法、刑法学科的比较法论文的显性与隐性比例分别为 1∶1.34、1∶1.11；反之，体系化程度越低的二级学科从事隐性比较法研究的比例也越低，如宪法与行政法、商法学科的比较法论文的显性与隐性比例分别为 1∶0.42、1∶0.88。这一差异不仅反映出体系化程度对比较法研究范式的塑造力，而且再次印证了比较法研究从显性向隐性转型发展的趋势。

〔52〕 参见高鸿钧：《美国法全球化：典型例证与法理反思》，《中国法学》2011 年第 1 期，第 9 页以下。

四、双重约束条件下的比较法研究范式

实证研究发现了中国比较法从显性向隐性转型的趋势。隐性比较法受制于两个约束条件，以其为分析工具，还可窥得中国比较法的未来。

第一，本土问题及其社会语境的约束。中国比较法的转型趋势是回归本土问题及其社会语境来审视并运用域外法，一旦回归本土问题，社会语境的约束就将随之而来。因为社会语境既是法律问题产生的土壤，也是分析问题、解决问题的限制条件。学者只要关注比较法对于解决本土问题之意义，自然不会忽视社会语境的约束。〔53〕这一约束机制有望塑造蕴含中国文化特质的比较法学。

第二，本国法体系的约束。如果说问题的社会语境只是一种潜移默化的软约束的话，本国法体系则是一种更为直接、有形的硬约束，因为“法网”之上任何一个“节点”都受到周边概念和规范的牵引。这种体系约束机制不仅限制了域外比较对象的选择（可比性），而且对域外法素材的应用和本国问题的解决也限定了条件（规范依据）。这一约束机制有望塑造蕴含中国法特质的比较法学。

以上两个约束条件对比较法研究范式的塑造作用各有侧重。前者要求比较法研究不脱离本土问题和社会语境，这强调尊重事实；后者要求比较法研究不脱离本国法体系，这强调尊重规范。事实和规范在法的运作上始终处于交互联动的状态，二者的交互作用将逐步塑造比较法的研究目标、比较方法和域外法素材的应用方式。这三个要素共同构成了隐性比较法的整体研究范式。

（一）双重约束条件下的比较法研究目标

隐性比较法总体上是一种问题导向和目标导向的研究。其中，事实层面的目标主要是解决本土社会问题；规范层面的目标主要是通过比较法研究解决本国法的解释与体系优化问题；当然还有理论层面的目标，〔54〕即通过不同法律样本的比较提炼一般法理论。在事实与规范的互动中，隐性比较法将朝着以下目标发展：立足本土问题，回归社会语境和本国法体系，通过域外比较解释法律、发展法律、优化体系、提炼一般法理论。

上述目标将引领隐性比较法在双重约束条件下保持相对清晰的发展路径。其中，作为法解释工具的比较法将日益盛行，它将从本国法的文义出发、尊重规范体系、立足社会现实，这不仅限定了域外法的比较对象，而且决定了域外法的用途。广义的法解释学还包括发展法律、优化体系的任务，〔55〕这既属于漏洞补充意义上的解释论研究，也属于为修法做准备的立法论研究，〔56〕但均将通往体系修复式的方向。此外，提炼法学理论的比较法也有相当的市场，它将从不同时代、民族和地域的法律样本中提炼法的一般概念、要素与原理，追求知识的一般化与

〔53〕 关于社会语境在比较法研究中的重要性，参见 Mark Van Hoecke & Mark Warrington, *Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a New Model for Comparative Law*, 47 Int'l & Comp. L. Q. 495, 496 (1998)。

〔54〕 一般法理论的研究在任何时候、任何领域都有重要价值，即便是法解释学主导下的民法也是如此。相关分析，参见冯珏：《新时代民法学研究的使命》，《民主与法制时报》2023 年 4 月 27 日第 5 版。

〔55〕 这种广义的理解，参见［德］卡尔·拉伦茨：《论作为科学的法学的不可或缺性——1966 年 4 月 20 日在柏林法学会的演讲》，赵阳译，《比较法研究》2005 年第 3 期，第 148 页，第 154 页。

〔56〕 新法能否融入既有法律体系，显然是一项以体系化为中心的法教义学研究任务。诚如拉伦茨所言，“如果一部法律要有较强的生命力，那么立法者事先就必须对有待规范的生活关系、对现存的规范可能性、对即将制定的规范所要加入的那个规范的整体、对即将制定的这一部分规范必然施加于其他规范领域的影响进行仔细的思考和权衡”。同上引拉伦茨文，第 154 页。

抽象化，这种“关于实在法但又超越实在法”的研究，[57]一定程度上也受到社会语境和法体系的潜在影响。总体上，“体系后”时代的隐性比较法重在服务本国法体系的融贯性发展，这将再次强化体系约束机制。可以说，体系约束既是塑造隐性比较法研究范式的原因，也是其结果。

例如，民事公益诉讼的比较法研究以2012年为界，在研究目标和路径上呈现出明显的变化。由于立法缺失，2012年之前，显性比较法更胜一筹，学者们凭个人兴趣自由介绍和比较域外立法模式，[58]或提炼公益诉讼的一般原理和制度移植条件。[59]2012年民事诉讼法确立了中国版本的公益诉讼制度后，原告被限定为“机关和有关组织”，这一体系约束使后来的比较法研究纷纷转向本国法的解释与体系优化方向。其中，法解释方向的研究，如通过域外比较为原告资格认定提供解释方案，比较对象也倾向于选择具有家族相似性的德国团体诉讼为蓝本；[60]体系优化方向的研究，如通过域外比较为我国两类群体性诉讼（代表人诉讼和公益诉讼）的体系分工提供优化建议；[61]一般法理论的研究，如追问个人和团体何以拥有公共事务之诉权，凡存在或拟引入公益诉讼的国家都面临该一般法理论之追问，因而在立法前后都不乏此类研究成果。[62]

（二）双重约束条件下的比较方法

在方法论上，比较法研究的关键环节在于，如何将两个事物放在同一个框架下进行比较，以及比较哪些具有可比性的内容和范畴，本文统称为“比较方法”。学界常用的比较方法如下：（1）规范比较，主要是对各国法进行文本和体系上的比较，致力于寻找法律规范的近似性和可比性。（2）功能主义比较，其关注点是文本背后的功能，这种比较不在意规范文本之异同，而是重在比较各国应对相同问题之方法的异同。上述两种比较方法都可能因发现近似性而支持法律借鉴与移植。（3）文化主义比较，这种比较方法超越法律文本，回归不同国家的历史文化和社会背景来理解其法律，研究结论往往排斥法律移植。文化主义比较的旨趣在于理解他者，即“了解特定国家何以会具有那样的法律”。[63]

在双重条件的约束下，比较方法也将有章可循，纯粹的规范比较将日渐式微，功能主义和文化主义比较将大有可为。由于隐性比较法是一种问题导向和目标导向的研究，而一国的法律文本与社会现实之间往往存在一定距离，只要关注问题如何解决，研究者自然会回归社会语境观察“行动中的法”，此时规范比较只有在两国的问题及其社会语境相同或类似，且法体系亦近似时，才有意义，但这两个约束条件同时满足的情况并不常见。因此，规范比较的应用空间有限，引入功能和文化视角将成为大势所趋。功能主义比较不受文本约束，但要求问题及其社

〔57〕 参见雷磊：《法理论：历史形成、学科属性及其中国化》，《法学研究》2020年第2期，第23页。

〔58〕 如民事公诉、团体诉讼、公民诉讼、集团诉讼等立法模式。参见肖建国：《民事公益诉讼的基本模式研究——以中、美、德三国为中心的比较法考察》，《中国法学》2007年第5期，第129页以下；罗健豪：《美国被告集团诉讼制度及对我国的启示》，《法学》2007年第9期，第154页以下；吴泽勇：《德国团体诉讼的历史考察》，《中外法学》2009年第4期，第589页以下。

〔59〕 参见范愉：《集团诉讼问题研究——一个比较法社会学的分析》，《法制与社会发展》2006年第1期，第74页以下。

〔60〕 参见宋宗宇、郭金虎：《扩展与限制：我国环境民事公益诉讼原告资格之确立》，《法学评论》2013年第6期，第61页以下；高琪：《我国环境民事公益诉讼的原告适格限制——以德国利他团体诉讼制度为借鉴》，《法学评论》2015年第3期，第143页以下。

〔61〕 参见熊跃敏：《消费者群体性损害赔偿诉讼的类型化分析》，《中国法学》2014年第1期，第196页以下。

〔62〕 参见吴泽勇：《群体性纠纷解决机制的建构原理》，《法学家》2010年第5期，第92页以下；巩固：《环境民事公益诉讼性质定位省思》，《法学研究》2019年第3期，第127页以下。

〔63〕［美］格伦顿、戈登、奥萨魁：《比较法律传统》，米健等译，中国政法大学出版社1993年版，第8页。

会语境近似，它“强调不简单地从条文出发，而是从问题出发，只要被比较的国家或地区具有相同的或类似的社会问题和需要，就可以对它们不同的应对办法加以比较”。[64] 而文化主义比较重在解释各国在其独特的环境下为何会有独特的法律，若关注“行动中的法”，则文化主义比较将获得更好的解释力和应用空间。

国内关于惩罚性赔偿的比较法研究生动地证明了上述判断。学界早期主要从规范层面比较中美两国惩罚性赔偿的近似性，[65] 认为中国法移植于美国。[66] 随着研究的深入，当回归问题的社会语境、关注“行动中的法”之后，学者发现中国的惩罚性赔偿规则难有惩罚效果，[67] 与美国法的惩罚功能悬殊极大，中国法重在“奖励”私人维权。[68] 真正具有功能近似性的是中国的行政罚款与美国的惩罚性赔偿。[69] 这是从规范比较转向功能比较之典范。若追问美国的惩罚性赔偿为何类似于中国的行政罚款，则会发现法律文化的解释力。中国源远流长的行政国家特点塑造了发达的罚款制度，而美国是一个对行政权保持警惕并主要依赖法院和私人诉讼应对社会问题的国家，这种文化分野造就了两国法的上述差异。因此，一旦回归社会语境和法体系的约束，则比较法的功能主义和文化主义转向便成大势所趋，这有助于推动比较法向法治实践的纵深方向发展。

（三）双重约束条件下的域外法素材应用方式

比较是为了增进了解，在充分了解的基础上，如何应用域外法素材，还需经过一个内化的过程。由于社会语境的差异，域外经验往往需要不同程度的重构才能为我所用，有时还要对本土文化进行引导和调试，通过双向调试才能增进域外法素材的应用价值。这一内化过程需要妥当的分析方法，这是比较法研究范式的最后一环。学界总结了三种常见的域外法素材应用方式：[70]（1）作为形式论据，这种方式主要是从法律文本出发，将域外法的概念、规范或原理作为讨论本国问题的基准和参照系；（2）析出分析框架，这种方式重在提炼域外法的分析框架和模式，借此为分析本国问题提供框架或思路；（3）获得启示意义，这种方式主要是将域外法的经验或教训作为获得启示的来源，而非从文本或制度上加以应用。

在双重条件的约束下，域外法素材的应用方式也将有章可循，直接将域外法作为形式论据的做法将逐渐式微，从域外法中析出分析框架、获得启示意义将成为主流。由于“纸面上的法”常常不同于“行动中的法”，以域外法作为形式论据不仅受到两国法的价值观念和法体系近似性的约束，而且受到两国面临的实际问题及其社会语境相似性的约束，任何一个条件的欠缺都可能导致“南橘北枳”。因此，将域外法作为形式论据的应用方式高度依赖价值层面的论

〔64〕 前引〔36〕，解亘文，第 10 页。

〔65〕 国内早期的研究主要从惩罚性赔偿制度的起源、功能、适用范围、适用条件、赔偿数额等角度进行中美比较。参见王利明：《惩罚性赔偿研究》，《中国社会科学》2000 年第 4 期，第 112 页以下；朱凯：《惩罚性赔偿制度在侵权法中的基础及其适用》，《中国法学》2003 年第 3 期，第 91 页以下。

〔66〕 “在美国、日本等国家的立法中，就有关于惩罚性赔偿的规定……我国在立法中予以规定，可以说是吸收国外立法经验的一个具体表现。”国家工商行政管理局条法司编著：《消费者权益保护法释义》，长春出版社 1993 年版，第 119 页。

〔67〕 参见应飞虎：《知假买假行为适用惩罚性赔偿的思考——基于法经济学和法社会学的视角》，《中国法学》2004 年第 6 期，第 114 页以下。

〔68〕 参见李友根：《惩罚性赔偿制度的中国模式研究》，《法制与社会发展》2015 年第 6 期，第 109 页。

〔69〕 参见赵鹏：《惩罚性赔偿的行政法反思》，《法学研究》2019 年第 1 期，第 47 页以下。

〔70〕 参见［日］大村敦志等：《民法研究指引：专业论文撰写必携》，徐浩等译，北京大学出版社 2018 年版，第 76 页以下。

证和规范效果的评估。相较之下，从域外法中析出分析框架讨论本国问题，重在利用域外法的分析工具，这对两国法体系的家族近似性要求不高，只要面对的问题及其社会语境相似，域外法的分析工具就可能有参考价值。最具应用前景的是从域外法中获得启示意义，哪怕社会语境不同、法体系也不近似，域外法的成功经验或失败教训在某种程度上都有一定的启发意义。因此，后两种域外法素材的应用方式在隐性比较法中将日益盛行。

以个人信息保护为例，早期的显性比较法可自由探讨美国、德国（及欧盟）的两种权利模式（防御性隐私权和支配性的个人信息自决权）。〔71〕然而，一旦回归本土社会语境和本国法体系的约束，美、德两国的权利概念均无法为解决中国问题提供形式论据。因为美国的防御性隐私权源于其根深蒂固的市场自治观念和崇尚行为自由的宪法价值，德国的个人信息自决权源于人格尊严在德国宪法上至高无上的地位，〔72〕一切都源于其宪法根基，而中国在个人信息保护与数字经济发展的二元价值冲突问题上面临的社会语境与法体系约束，既不同于美国，也不同于德国，因而无法照搬适用，但可借鉴其分析框架。个人信息保护的私法框架在国际上不外乎积极确权和行为规范两套体系，二者的联动可为权益保护和数据开发利用的二元价值提供双边裁量平台。〔73〕这种分析框架完全可用于分析中国面临的价值冲突难题。在启示意义方面，美国对个人信息的弱保护孕育了强大的数字经济产业，德国对个人信息的强保护赢得了人本主义价值的回归与社会信任。凡属价值冲突问题，任何选择都伴随着一定的收益和代价，这种启示意义具有普遍性。

五、迈向自主法学知识体系的比较法学

行文至此，终于可以对“比较法向何处去”这一问题作出回答：无论是从国家法治发展的进程来看，还是在学说论辩的脉络之下，比较法在中国都没有也不应走向衰落，其正处于从显性比较法向隐性比较法的转型发展之中。沿着这一转型方向，比较法的研究范式也将在本土社会语境和本国法体系的双重约束下得以塑造。这一研究范式蕴含着比较法学主体意识回归的积极信号，而主体意识的回归又是构建自主法学知识体系的关键条件。在这个意义上，隐性比较法的研究范式总体上契合了中国法治的发展进程。

（一）比较法学主体意识回归的积极信号

隐性比较法在研究目标、比较方法和域外法素材的应用方式三个层面均蕴含着本国主体意识回归的积极信号。首先，隐性比较法的研究目标是立足本土问题、服务本国法治，通过拓展域外视野来解释法律、优化体系、提炼原理，一切都围绕中国问题这个中心点开展，这是主体意识回归的基点。其次，比较方法也将从文本层面的规范比较，转向功能主义和文化主义的深度比较，由于法的功能深嵌于一国的社会语境中，加之文化主义视角的引入，使得域外法不再被视为普适的公理，域外法有无借鉴意义要回到本土社会的语境下才能作出评判，这是主体意识回归的路径。最后，域外法素材主要以解决本土问题的论据方式呈现，论据的分析应用也不

〔71〕 See Paul M. Schwartz & Daniel J. Solove, *Reconciling Personal Information in the United States and European Union*, 102 Cal. L. Rev. 877, 881 (2014).

〔72〕 See James Q. Whitman, *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty*, 113 Yale L. J. 1151, 1180-1189 (2004).

〔73〕 参见宋亚辉：《个人信息的私法保护模式研究——〈民法总则〉第111条的解释论》，《比较法研究》2019年第2期，第96页以下。

再是抽离社会语境的生搬硬套，而是通过从域外法中析出分析框架或提炼启示意义来讨论中国问题，这从方法论上实现了主体意识的回归。

主体意识的回归契合了中国法治的发展进程。改革开放早期自由绽放的显性比较法重在搬运域外法律知识为本国立法提供参考资料，不拘一格的搬运方式为初创期的法学增添了繁荣气象。但随着我国立法框架的逐步形成，法治建设的重心开始向实践转移，法学研究的使命也正在调整。如学者所言，“在立法主导法学发展的时代结束以后，学术界的首要任务就是要同化这些外来的法律制度，构建中国自己的部门法知识体系，为中国的司法部门提供现实的知识辅助”。〔74〕在此背景下，各部门法的研究范式也陆续转型升级，〔75〕比较法亦然。隐性比较法回归本土问题审视域外法，在问题的社会语境和本国法体系的双重约束下从事比较法研究，这有助于确立本国的主体意识，以自身发展需要来看待域外经验。

主体意识的确立对于转型国家的法治建设意义重大。“二战”后，在第三世界国家兴起的“法律与发展运动”走向衰落的关键原因即在于法律继受国缺乏主体意识，西方中心主义范式主导了这场运动。〔76〕法律继受国一旦丧失主体意识，域外法极易被视为普适的公理进行移植，其成败难测，教训深刻。〔77〕因此，主体意识的回归有助于纠偏西方中心主义立场，法律移植应以继受国自身的需要来比较和借鉴域外法，在知己知彼的基础上自主设定改革议程。当下中国的法治实践正面临着如何同化外来概念和规则的任务，本国主体意识的回归可谓正当其时，这不仅有助于自主法学知识体系的构建，而且顺应了全球法律文明从“理性法”向“多元主义法”演进的趋势。〔78〕

（二）“文化依赖论”承载着更深层次的主体意识

比较法的中国样本也为全球性的学说论辩提供了新的素材和论据。比较法在中国从显性向隐性的转型发展，间接反映出学界对法律移植命题所持观念的调整，即从“法律移植论”转向“文化依赖论”。这一判断背后的推理逻辑是：若法律可以跨地域自由移植且不受本土文化约束，则自由绽放的显性比较法在中国法治转型中将大有可为；反之，若本土文化是法律的核心塑造力量，则回归本土社会语境的隐性比较法才有实际意义。据此来看，国内早期显性比较法的盛行反映出学界对“法律移植论”持有相对乐观的态度，而 2011 年之后显性比较法的衰落则反映出学界对早期观念的反思与调整，调整方向是关注“行动中的法”，这为“文化依赖论”的出场铺就了道路，历史上的“文化依赖论”正是由于关注法与社会的互动关系而产生的。〔79〕需要说明的是，国内学术观念向“文化依赖论”靠拢，并不是因为法律移植命题被

〔74〕 卜元石：《德国法学与当代中国》，北京大学出版社 2021 年版，第 19 页。

〔75〕 如刑法从四要件向三阶层分析范式的转型，民法从立法论向解释论范式的转型，经济法从调整对象之争向问题导向的学术研究转型，宪法从单一的政治宪法学向宪法解释学、规范宪法学的多元研究范式转型等。

〔76〕 该运动的主要发起者事后曾有深刻反思。参见［美］戴维·杜鲁贝克：《论当代美国的法律与发展运动（上）》，王力威译，《比较法研究》1990 年第 2 期，第 48 页。

〔77〕 约翰·梅利曼也总结了这场运动的启示：“有意识的法律改革需要建立在对法律与社会之间关系的某种假设基础上，最常见和最基本的假设是将法律视为社会的一个组成部分。” See John Henry Merryman, *Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline and Revival of the Law and Development Movement*, 25 Am. J. Comp. L. 457, 464 (1977).

〔78〕 See Timothy D. Batdorf, *Beyond Rationality: Using Integral Theory to Understand the Evolution of Law and Legal Systems*, 32 T. M. Cooley L. Rev. 293, 298-301 (2015).

〔79〕 劳伦斯·弗里德曼作为“文化依赖论”的奠基者，正是通过反思文本之法，并将研究视角转向法与社会互动的轨道后，才发现了法律文化的塑造作用。See Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, 4 Law & Soc. Rev. 29, 33 (1969).

证伪，而是学者观察视角的转变，以不同的视角将会看到不同的证据和样本。[80] 例如，对中国法制建设初期的立法本文进行比较，很容易获得支持“法律移植论”的证据；[81] 但若对法的实践效果进行比较，则将获得支持“文化依赖论”的证据。[82] 这似乎也是法律移植命题在国际上争论不休的原因。

由此可以看出，在比较法研究范式转型的这条明线背后，还隐含着一条学术观念转变的暗线。随着国内的学术视角越来越多地转向“行动中的法”，学者将会围绕法治实践效果的差异形成更多支持“文化依赖论”的学说，这将进一步凸显本土文化对中国法治的塑造作用。这样的研究趋势无疑会提升比较法学者的文化自觉性，一种更深层次的主体意识将因此逐渐确立。因为，根深蒂固的民族文化在任何时候都是最深刻、最真实的身份烙印，尊重法治发展背后的文化约束和文化脉络，将是一种更深层次的主体意识的回归。

（三）主体意识是迈向自主法学知识体系的关键一步

主体是相对于客体来说的，无论对于个人还是国家而言，主体意识的确立都意味着独立自主的存在；而客体是依附于主体的附属物，丧失主体意识意味着对他人的依附。从主客体关系的逻辑来看，任何“自主”都需要建立在坚实的“主体意识”之上。因此，主体意识的回归乃是构建自主法学知识体系的关键。回顾十多年前学界关于“中国法学向何处去”的大讨论，当时论辩的焦点问题——“当下中国的问题意识”和“主体性中国”，[83] 已蕴含在隐性比较法的研究范式中。隐性比较法的盛行意味着越来越多的学者正在回归中国问题、正视本土文化，这是塑造主体性中国的关键一步，也是迈向自主法学知识体系的关键一步。

但无论是主体意识的回归，还是自主知识体系的构建，都不应排斥国际视野和域外经验。因为主体性强调的是独立意志，自主性强调的是自我决定、不依附于他人，这与自主吸收域外经验并不矛盾。更何况，一国在全球化时代的主体性不是在自我封闭中树立的，而是在与他国保持主体性间互动的过程中形塑的，也是在国际对话中因尊重彼此的主体性而相互成就的，是一种“和而不同”的主体性。比较旨在增进了解，了解他者，才能深度剖析自我，进而才能在国际对话中更好地坚守主体意识，在知己知彼中追求自主性。这对发展中国家尤其重要，“发展中国家要想实现法律现代化，就不应拒斥包括西方在内的法律智慧和经验，因为在封闭状态下进行的法律现代化尝试，至今没有成功的先例”。[84] 通过比较法发现他国的前车之鉴，不仅有风险提示之功效，还能在知识共享中实现超越，这种后发优势怎能拒绝？法国、德国这些法治发达国家，是以继受罗马法为起点而成就了 19、20 世纪的民法典范，日本作为后起之秀，也是通过借鉴德国法、法国法才造就了日本法的自主体系。[85] 在当前国际竞争的局势下，国际话语权的争夺更是离不开比较法的贡献，“打造中国概念和理论的同时，须以其他国

〔80〕 例如，按区分规则类型的视角，伦理性规则高度依赖地域文化才能落地生根，但一些价值无涉的规则（如所有权）以及源于人类纯粹理性的法则（如诚实信用），不仅没有移植障碍，甚至被视为科学知识而传播。

〔81〕 我国历次民法典的起草便是例证。相关考证，参见何勤华、周小凡：《我国民法典编纂与德国法律文明的借鉴——中国继受 1900 年〈德国民法典〉120 年考略》，《法学》2020 年第 5 期，第 167 页以下。

〔82〕 代表性成果，参见苏力：《法治及其本土资源》，中国政法大学出版社 2004 年版，第 3 页以下。

〔83〕 参见邓正来：《批判与回应：寻求中国法学的主体性》，《浙江社会科学》2006 年第 1 期，第 6 页以下。

〔84〕 前引〔52〕，高鸿钧文，第 38 页。

〔85〕 日本对外国法的借鉴也经历了一个调适过程。例如，日本民法在学说继受期（19 世纪末至 1920 年代）“经常出现仅因德国法十分出色就将其当作范本的情况。……然而，现今的共识却是，不能积极地利用基于范本的论述方法作出提议。既然历史、文化、社会不同，那么就难以把特定的国家当作典范看待”。前引〔70〕，大村敦志等书，第 68 页。

家和其他文明能够听得懂的方式予以传播”。[86] 因此，比较法在当今中国依然重要。

本文褒扬隐性比较法的价值，但并不因此排斥显性比较法的存在意义。改革开放早期显性比较法的知识搬运现象引发了一定的担忧，但对“西方理论搬运工”的真正担忧在于本国主体意识缺失的风险，只要坚守主体意识，无论显性还是隐性比较法，都能为法治建设作出贡献。[87] 比较的前提是知己知彼，隐性比较法难以容纳对域外法体系脉络的整体介绍，因而“知彼”的过程有赖显性比较法的贡献。从长远看，显性比较法的价值也绝不限于为隐性比较法提供域外知识的辅助，自由绽放的显性比较法有其独立存在的价值。当比较法学者没有了策论的实用目的、不必受制于个案的急迫需要、超脱了功利主义的心态，反而可能作出更具生命力的学术贡献。在多元法律文明的演化进程中，同样需要有人超越应对本土问题的内部视角，以更开放的视野、更博大的胸怀和真正的国际主义精神，在贯通全球法律文化的基础上探索人类法治文明的演进方向，而这并非隐性比较法的研究范式所能企及者。因此，显性比较法同样重要，但其核心使命不再是简单搬运域外法律知识，而应是在尊重各国主体性的基础上推动法律文明的研究、互鉴和交流。

Abstract: The rise of comparative law in contemporary China stems from the mission of serving legislative activities. The research paradigm of comparative law has undergone a process of transformation along with the development of the Socialist Legal System with Chinese Characteristics. The “explicit comparative law”, which takes the introduction of and comparison among foreign laws as its theme, has gradually declined, while the “implicit comparative law”, which explores domestic problems by using foreign laws as arguments, has gradually become the mainstream. The selection of objects of comparison is increasingly constrained by the domestic legal system and the similarity of legal families has become a decisive factor in the selection. These two trends have profound implications. Since legal issues are always deeply embedded in local society, their social context becomes a constraining factor of implicit comparative law research. The social context and the domestic legal system not only shape the objectives of comparative legal research but also limit the selection of comparison objects in foreign laws. They also affect the approach to comparison and the methods of analyzing foreign law materials. These elements collectively constitute the research paradigm of implicit comparative law with Chinese characteristics, which contains a positive signal of the return of subjective consciousness of China. The return of subjective consciousness is a key step in building independent jurisprudential knowledge system and is also generally in line with the development process of the rule of law in China.

Key Words: comparative law, legal transplant, legal families, paradigm transformation, independent jurisprudential knowledge system

〔86〕 前引〔36〕，刘晗文，第 80 页。

〔87〕 作为前车之鉴，日本民法学经历了从昭和后期多元比较法的学风到平成时代回笼于本国法教义学的单一风格的转变，在学者看来，这“给日本民法学所留下的遗憾，恐怕并不比成就来的少”。章程：《也是西风渐东土——〈民法研究指引〉的指引》，《交大法学》2021 年第 2 期，第 197 页以下。